

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第二講 解釋要旨

五權分治、平等相維

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈五權分治、平等相維〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
1 (38.01.06)	立委未經辭職兼任官吏者，應於就任官吏時視為辭職。	§75	[水平分權] Q §75 立意？ Ω 避免因角色混淆，而破壞分權制衡設計。然何以內閣制閣員率由議員兼任？我國何以不採？
3 (41.05.21)	監察院關於所掌事項有向立法院提案之權。	§71 [釋 175]	[權力相互制衡] Q 按「五權分治、平等相維」之設計，監察院亦應如司法院般，得單獨向立法院提出概算（Cf. 增修 §5-VI）？
4 (41.06.20)	聯合國韓國委員會我國副代表為憲法所稱之「官吏」。	§75 [釋 1]	[水平分權] Q 避免利益衝突，破壞分權制衡？
14 (42.03.21)	各級民意代表不受監察院糾彈。	§97 [釋 33]	[權力相互制衡] Q 民意代表受民意監督，便無受「監察」之必要？
15 (42.04.24)	國民大會代表代表國民行使政權，自係公職。依憲法第一百零三條之規定，監察委員不得兼任。查憲法第一百條及第二十七條，將對於總統、副總統之彈劾與罷免劃分，由監察院與國民大	§103	[水平分權] Q 本件採用哪種解釋方法？ Ω 兼採文義解釋、論理解釋、體系解釋&歷史解釋

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
15 (續)	會分別行使，若監察委員得兼任國民大會代表，由同一人行使彈劾權與罷免權，是與憲法劃分其職權之原意相違，其不應兼任更屬明顯。再查憲法草案第二十六條第一款及第二款，原列立法委員、監察委員得為國民大會代表，嗣有代表多人，認為於理無當，提出修正案若干起，制憲大會依綜合審查委員會之意見，將該條第一、第二兩款刪去，亦可為不得兼任之佐證。		
19 (42.06.03)	憲法第一百零三條所稱不得兼任其他公職，與憲法第七十五條之專限制兼任官吏者有別，其含義不僅以官吏為限。	§103	[水平分權] Q 因監察之範圍不限於「官吏」？
20 (42.07.10)	人民團體（政黨）之職員非屬「公職」； 監委不得從事醫務。	§103	[水平分權] Q 系爭業務與監委職權顯不相容？ Ω 監委兼任黨職洵無利益衝突？ Cf. §88, 增修 §7-V
30 (42.12.29)	憲法第七十五條雖僅限制立法委員不得兼任官吏，但並非謂官吏以外任何職務即得兼任，仍須視其職務之性質，與立法委員職務是否相容。同法第二十七條規定國民大會複決立法院所提之憲法修正案，並制定辦法行使創制、複決兩權，若立法委員得兼國民大會代表，是以一人而兼具提案與複決兩種性質不相容之職務，且立法委員既行使立法權，復可	§75	[水平分權] Q 兼職（國大）之性質與本職（立委）何以不相容？ Ω 既「提（憲法修正案）」於前，又「複決」於後，殆無制衡可言。

02 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
30 (續)	參與中央法律之創制與複決，亦顯與憲法第二十五條及第六十二條規定之精神不符，故立法委員不得兼任國民大會代表。		
33 (43.04.02)	議長處理會務如有不當，應由議會制裁，非屬監察對象。	§§97-II, 98 [釋 14]	[權力相互尊重] Q 因議會自律關係立法權之獨立運作？
38 (43.08.27)	法官審判以法律為主要依據，並非此外與憲法或法律不相牴觸的有效規章均行排斥不用。	§80 [釋 137] [釋 216] §§23, 125	[權力相互制衡] Q 「依法審判」包括保障法官認定何者為「法」的權力？
	縣立法（規章）如無憲法或其他法律之依據，不得限制人民自由。		[垂直分權] Q 中央立法比地方立法更能保障人權？
74 (46.03.22)	國民大會代表係各在法定選舉單位當選，依法集會，代表全國國民行使政權。而省縣議會議員乃分別依法集會，行使屬於各該省縣之立法權。為貫徹憲法分別設置各級民意機關賦予不同職權之本旨，國民大會代表自不得兼任省縣議會議員。	§28	[垂直分權] Q 何謂「貫徹憲法分別設置各級民意機關，賦予不同職權之本旨」？ Ω 中央民代兼任地方民代破壞垂直分權？
75 (46.04.08)	查制憲國民大會對於國民大會代表不得兼任官吏，及現任官吏不得當選為國民大會代表之主張，均未採納。而憲法第二十八條第三項僅限制現任官吏不得於其任所所在地之選舉區當選為國民大會代表。足見制憲當時並無限制國民大會代表兼任官吏之意，故國民大會代表非不得兼任官吏。	§28	[水平分權] Q 本件與釋字 30 之見解矛盾？ Ω 國大原屬無給職（Cf. 釋字 282），且非經常集會。許其兼任官吏，鮮有利益衝突。

《對話憲法・憲法對話》2015

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第二屆（47.09～56.08：釋字 80～122）			
86 (49.08.15)	憲法第七十七條所定司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事訴訟之審判，係指各級法院民事、刑事訴訟之審判而言。高等法院以下各級法院及分院既分掌民事、刑事訴訟之審判，自亦應隸屬於司法院。	§77	[權力相互制衡] Q 貫徹憲法「司法獨立」之本旨？ Ω 法院組織隸屬攸關人事及預算，實質上影響「審判獨立」
122 (56.07.05)	地方議會議員言論，憲法未有保障規定，本院院解字 3735 號解釋不違憲。	§§32, 73, 101 [院解 3735]	[權力相互制衡] Q 議員言論免責（特）權不得逾越其行使職權所必要之範圍？
第三屆（56.09～65.09：釋字 123～146）			
137 (62.12.14)	法官審判案件時，對行政機關所作有關法規釋示的行政命令仍得表示其合法適當的見解。	§80 [釋 38] [釋 216] [釋 530]	[權力相互制衡] Q 保障法官有認定何者為「法」之權力，始足維護「審判獨立」？ Ω 本件所見不如釋字 38？
第四屆（65.09～74.09：釋字 147～199）			
155 (67.12.22)	考試院為國家最高考試機關，得依法定職權訂定考試規則及決定考試方式。	§§83, 85, 18	[權力相互制衡] Q 放寬「法律保留」原則，方便考試權之行使？ Ω 辦理考試屬於「立法」或「行政」行為？
165 (69.09.12)	地方議會議員會議言論應受保障，本院釋字第一二二號解釋應予補充。	§§32, 73, 101 [釋 122]	[權力相互制衡] Q 本件與釋字 122 之差別？ Ω 正面肯定地方議會議員亦有「言論免責特權」

02 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
175 (71.05.25)	司法院就所掌事項得向立法院提出法律案。	§77 [釋 3]	[權力相互制衡] Q 「五權分治，彼此相維」之憲法結構使然？
184 (72.12.23)	地方政府編製年度總預算，經審計機關審核後所提出之審核報告，地方議會審議時，不得要求審計機關提供審定之原始憑證。	§§90, 104	[權力相互制衡] Q 本件解釋用意？ Ω 保障審計獨立。原始憑證與地方議會決算審議既「無直接關係」，一經審計機關審定應即告確定。
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
207 (75.07.18)	省市議會議員、議長不得兼任私立學校校長。	[釋 14] [釋 15] [釋 30]	[水平分權] Q 化解可能的利益衝突，須概禁止兼任？或於個案迴避即可？
216 (76.06.19)	法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨；司法行政機關所發司法行政上之命令，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，亦不受其拘束。惟如經法官於裁判上引用者，當事人即得依司法院大法官會議法第四條第一項第二款之規定聲請解釋。	§§15, 23 [釋 137]	[審判獨立]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
234 (78.03.03)	營業稅與印花稅雖為省（市）稅，仍得規定由中央統籌分配，以符合憲法謀求地方經濟平衡發展之意旨。	§§147, 107-VII	[垂直分權] Q 「合理調劑省市之所得」之意義？
235 (78.03.17)	審計權屬監察權範圍，應由中央立法並執行。審計部於省（市）設審計處並審計省（市）政府財務，並不違憲。	§§90, 107-XIII	[垂直分權] Q 何以不許地方自為監察（審計）？ Ω 監察（審計）乃中央「監督各省（市）預算之執行所必要」；我國並非「聯邦國」。
250 (79.01.05)	「現役軍人」不得兼任文官係指正在服役者，不含外職停役者。惟外職停役及其回役之程序，應通盤檢討，由法律直接規定。	§140	[水平分權] Q 停役者現時「既無軍權，乃無干政之虞」。然「外職停役」仍得「回役」（恢復現役軍人身份），將來如何處理？ Ω 本件與釋字 419 不同，似因 §140 僅限制「現役」軍人。
262 (79.07.06)	監察院對軍人提出彈劾案應移送公懲會審議。至其它軍人犯過犯依陸海空軍懲罰法行之。	§§77, 90, 97-II, 99, 100	[權力相互制衡] Q 本件如何維護監察權與司法權之完整？
314 (82.02.25)	國民大會臨時會非以修憲為目的而召集，自不得行使修憲權力。釋字第二十九號解釋應予補充。	§§29, 30, 174-1； 增修§§11-I, 11-II, 15 [釋 29]	[權力相互制衡] Q 理由書：修憲「關係憲改秩序之安定以及國民之福祉甚巨，應使國民預知其修改的目的並有表達意見

02 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
314 (續)			的機會」。此為「自由民主憲政秩序之原則」？ Ω 參見釋字 381。
319 (82.06.04)	考試卷彌封開拆後，除依形式觀察即可發現該項成績顯有錯誤者外，不應循應考人之要求任意再行評閱，以維持考試的公平與客觀。	§§15, 18	[權力相互尊重] Q 尊重閱卷委員的「判斷餘地」乃為維持考試（典試）權的公平與客觀？ Q 本件解釋如何在司法權與考試權間維持平衡？
328 (82.11.26)	憲法第四條稱「中華民國領土，依其固有疆域」有其政治與歷史理由。固有疆域的界定，為重大之政治問題，不應由司法機關予以解釋。	§4	[權力相互尊重] Q 司法機關何以不應參與政治決定（審理「政治問題」）？ Ω 避免司法介入政治爭議而喪失公信力？政治問題殆無法律上之正確答案，乃無從為「裁判」？司法機關不具民意基礎，不宜參與政治決定？
342 (83.04.08)	法律案經立法院移送總統公佈者，曾否踐行其議事應遵循之程序，乃至內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定之範圍，並非釋憲機關審查之對象。	§§63, 72, 37	[權力相互尊重] Q 「議會自律」之界限？
	但法律案立法程序有不待調查之事實即可認定牴觸憲法者，亦即		Ω 逾越「議會自律」範圍，即進入「司法

《對話憲法・憲法對話》2015

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
342 (續)	有違反法律成立基本規定之明顯重大瑕疵者，釋憲機關仍得宣告為無效。		審查」範疇。
357 (83.07.08)	審計部組織法第三條關於審計長任期為六年之規定，旨在確保其職位之安定，俾能在一定任期中，超然獨立行使職權，與憲法並無抵觸。	§104	[權力相互制衡] Q 審計長何以由總統提名，立法院同意，而隸屬監察院，並具固定任期？ Ω 乃為保障其獨立行使職權。
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
381 (84.06.09)	修改憲法所進行之一讀會程序，並非通過憲法修改案，其開議出席人數究採國民大會組織法第八條代表總額三分之一，或採憲法第一七四條第一項所定三分之二之出席人數，抑或參照一般會議規範所定出席人數為之，係屬議會自律之事項，均與憲法無違。	§174-I	[權力相互尊重] Q 出席人數之規定屬立法權之核心事項？ Ω 依法開會乃合議機關行使職權之前提。
	議會自律事項之決定，應符合自由民主憲政秩序之原則。		Q 何謂「自由民主憲政秩序之原則」？ Ω 指應經「思辯程序」(deliberative process)？ Cf. 釋字 314, 499
387 (84.10.13)	基於民意政治與責任政治之原理，行政院院長及其所屬部會首長（含政務委員）應於立法委員改選後第一次集會前提出總辭。	§§53, 55-I [釋 419-II]	[權力相互制衡] Q 非如此不能確保「行政院對立法院負責」？ Ω 立委改選後之總辭屬「義務性」辭職，總統就職時之總辭屬「禮貌性」辭職（釋字 419），兩者有別。

02 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
401 (85.04.26)	憲法第三十二條及第七十三條規定國民大會代表及立法委員言論及表決之免責權，係指國民大會代表在會議時所為之言論及表決，立法委員在立法院內所為之言論及表決，不受刑事訴追，亦不負民事賠償責任，除因違反其內部所訂自律之規則而受懲戒外，並不負行政責任之意。	§§32, 73 [釋 122] [釋 165] [釋 435]	[權力相互尊重] Q 言論及表決免責特權乃為使議員問政而無後顧之憂？ Q 何謂民意代表之「行政責任」？
419 (85.12.31)	副總統得否兼任行政院院長憲法並無明文規定，副總統與行政院院長二者職務性質亦非顯不相容，惟此項兼任如遇總統缺位或不能視事時，將影響憲法所規定繼任或代行職權之設計，與憲法設置副總統及行政院院長職位分由不同之人擔任之本旨未盡相符。引發本件解釋之事實，應依上開解釋意旨為適當之處理。	§75 [釋 1] [釋 4] [釋 24]	[水平分權] Q 縱與憲法原意「未盡相符」，又何妨？ Ω 利益衝突現時並不存在，未來發生之機率亦渺，何須禁止兼任？ Q 本件解釋於今仍有適用？
	行政院院長於新任總統就職時提出總辭，係基於尊重國家元首所為之禮貌性辭職，並非其憲法上之義務。對於行政院院長非憲法上義務之辭職應如何處理，乃總統之裁量權限，為學理上所稱統治行為之一種，非本院應作合憲性審查之事項。	§57	[權力相互尊重] Q 「禮貌性辭職」既非憲法上之義務，行政院長即無須總辭？ Ω 即便總辭，總統亦當「禮貌性慰留」，何能假戲真作（批准辭職）？
	依憲法規定，向立法院負責者為行政院，立法院除憲法所規定之事項外，並無決議要求總統為一定行為或不為一定行為之權限。		[權力相互制衡] Q 「行政院向立法院負責」，立法院與總統並無直接制衡關係？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
435 (86.08.01)	為確保立法委員行使職權無所瞻顧，憲法第七十三條言論免責權之保障範圍，應作最大程度之界定，舉凡在院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為，如院內黨團協商、公聽會之發言等均屬應予保障之事項。	§73 [釋 122] [釋 165] [釋 401]	[權力相互尊重] Q 「免責特權」乃為保障其行使職權，免責範圍自亦應以此為限？
	越此範圍與行使職權無關之行為，諸如蓄意之肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列。		[權力相互制衡] Q 此處兼有維護其他部門「權力」及他人「權利」之考量？
	於具體個案中，立法委員之行為是否已逾越保障之範圍，於維持議事運作之限度內，固應尊重議會自律之原則。		[權力相互尊重] Q 同釋字 401？
	惟司法機關為維護社會秩序及被害人權益，於必要時亦非不得依法行使偵審之權限。		[權力相互制衡] Q 逾越「免責特權」而侵害他人之權利，即屬（廣義）司法權之範圍？
461 (87.07.24)	立法院為行使憲法所賦予…職權，得依憲法第六十七條規定，設各種委員會，邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢…司法、考試、監察三院院長，本於五院間相互尊重之立場，並依循憲政慣例，得不受邀請備詢。	§67	[權力相互制衡] Q 何以司法、考試、監察三院院長得不受邀備詢乃五院相互尊重之表現？
467 (87.10.22)	增修條文(86/07/21) 第九條施行後，省自非地方自治團體性質之公法人。各項法律未劃歸國家或縣市等地方自治團體之事項，而	1997 四次增修 §3-II-(1)	[垂直分權] Q 地方制度(第十一)章之規定並非修憲之界限，實質廢省亦不

02 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
467 (續)	屬省之權限且得為權利義務之主體者，於此限度內，省自得具有公法人資格。		違憲？
499 (89.03.24)	第三屆國民大會於 88/09/04 第四次會議第十八次大會以無記名投票方式表決通過憲法增修條文 §§1, 4, 9, 10 之修正，其程序違背公開透明原則及當時適用之國民大會議事規則§ 38-II 規定，其瑕疵已達明顯重大之程度，違反修憲條文發生效力之基本規範；其中 §§1-I & II & III, 4-III 內容並與憲法中具有本質重要性而為規範秩序賴以存立之基礎，產生規範衝突，為自由民主憲政秩序所不許。上開修正條文應自本解釋公布之日起失其效力，86/07/21 修正公布之原增修條文繼續適用。	§§1, 2, 4, 7, 25, 26, 27, 28, 78, 79, 117, 133, 135, 171, 173, 174 增修§§1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 [釋 31] [釋 85] [釋 254] [釋 261] [釋 314] [釋 331] [釋 342] [釋 381] [釋 401]	[權力相互制衡] Q 「自由民主憲政秩序」乃憲法修改之界限？
	第一百七十三條顯非為一般性之憲法解釋及統一解釋而設，乃係指與憲法施行及修改相關之事項，一旦發生疑義，其解釋亦屬本院大法官之職權。至於相關機關所踐行之議事程序，於如何之範圍內為內部自律事項，何種情形已逾越限度而應受合憲性監督，則屬釋憲機關行使審查權之密度問題，並非謂任何議事程序皆得藉口內部自律事項，而規避其明顯重大瑕疵之法律效果。	[釋 419] [釋 721]	[權力相互尊重] Q 本件採取何種「審查標準」？ Ω 本件與釋字 342 採取不同「審查密度」？何故？

《對話憲法・憲法對話》2015

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
新制（92.10～：釋字 567～）			
632 (96.08.15)	監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，其院長、副院長與監察委員皆係憲法保留之法定職位，故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。為使監察院之職權得以不間斷行使，總統於當屆監察院院長、副院長及監察委員任期屆滿前，應適時提名繼任人選咨請立法院同意，立法院亦應適時行使同意權，以維繫監察院之正常運行。總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。	§§28, 49 增修 §§1, 2, 7	[權力相互尊重] Ω 憲法機關消極拒不行使職權應有界限--不得因而癱瘓其他憲法機關之運作，破壞分權制衡之憲法結構。
645 (97.07.11)	公民投票法第十六條第一項使立法院就重大政策之爭議，於必要時交付公民投票，不違反我國代議民主之原則，亦符合人民有創制、複決權之意旨；此一規定於立法院行使憲法權限範圍內，且不違反權力分立之原則下，與憲法尚無牴觸。	§§2, 17, 27, 53, 56, 62, 63, 136, 174 增修§§1, 3, 12 [釋 342] [釋 520]	[權力相互制衡] Q 何謂「且不違反權力分立之原則」？